



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

תיק מס': 250/13

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

התובעים:

1. שמעון מועלם

2. מרים מועלם

ע"י ב"כ עו"ד אהרון אגסי

- נ ג ד -

הנתבע:

יוסף סליימן

ע"י ב"כ עו"ד גלעד נרקיס

פסק-דין

עניינו של פסק דין זה בטענה להסגת גבול של הנתבע אל תחומי דירת התובעים. השאלה העיקרית בה יש לדון במסגרת פסק הדין היא האם אכן רכשו התובעים את שטח הדירה כולה או שמא רכשו אותה מלכתחילה כך שהשטח בו מחזיק הנתבע נגרע ממנה. ככל שאכן רכשו התובעים את הדירה בשלמותה- האם קיימות לנתבע זכויות הגוברות על אלו של התובעים לדרוש את סילוק ידו.

א. העובדות

1. עסקינן בבית משותף הידוע כגוש 30082 חלקה 61 והמצוי ברחוב עמוס 19 בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**").
2. חלקת משנה 1 היא בבעלות התובעים (להלן: "**דירת התובעים**" או "**הדירה**"). על פי הרישום במרשם המקרקעין שטחה הוא 41.6 מ"ר.
3. חלקת משנה 2, אשר שטחה הוא 15.3 מ"ר לפי הרשום במרשם המקרקעין, ומשמשת כחנות, היא בבעלות הנתבע. לחלקת משנה 2 צמודה בהצמדה מיוחדת רחבת כניסה בשטח של 7.7 מ"ר (להלן: "**החנות**").
4. הנתבע היה בעליה של הדירה בעבר. בשנת 1999 שיעבד דירה זו לבנק המזרחי המאוחד בע"מ (להלן: "**בנק המזרחי**"). ככל הנראה בשלב מסוים חדל מלשלם את כספי ההלוואה והחלו נגדו הליכי גבייה, שכללו את מכירת הדירה באמצעות כונס נכסים אשר מונה לשם כך.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

5. הליכי מכירת הדירה נעשו באמצעות לשכת ההוצאה לפועל וכונס נכסים ולאחר הליך של התמחרות. הנתבע ניגש אף הוא להליך ההתמחרות אולם בסופו של יום זכו בו התובעים ורכשו בהתאם את הדירה ואף נרשמו במרשם המקרקעין כבעליה של יחידת משנה 1 בשלמות. התנגדויות שהגיש הנתבע לביצוע הליך המכירה - נדחו.
6. אין חולק בין הצדדים כי עוד טרם מכירת הדירה, סיפח הנתבע שטח של כ-5 מ"ר מהדירה אל החנות, ובתוך כך שינה בפועל את גבולותיהן של הדירה והחנות בהתאם (להלן: "**השטח המסופח**"). אין מחלוקת עוד כי במסגרת הליך ההתמחרות ציין כונס הנכסים עובדה זו. כמו כן מוסכם על שני הצדדים, כי השמאות על בסיסה הוצע מחיר הדירה לא כללה את השטח המסופח.
7. התובעים עותרים במסגרת הליך זה לסלק את ידו של הנתבע מ"השטח המסופח" ומחלקים נוספים אשר התברר לאחר רכישת הדירה כי פלש אליהם (מעין "בויזעם" השייך במקור לדירה וסופח אף הוא לחנות - להלן: "**הבויזעם**"), להשיב לתובעים את הדירה שלמה ופנויה ולחייבו בדמי שימוש ראויים בגין התקופה בה החזיק שלא כדין בשטח המסופח.
8. בהליך דנן הוגשו תצהירי עדות ראשית, התקיים דיון הוכחות ולאחריו הגישו הצדדים את סיכום טענותיהם בכתב. אציין כי בתחילת ההליכים בתיק, הצעתי לצדדים במהלך הדיון שהתקיים בפניי כי למען יעילות ההכרעה במחלוקת המרכזית ביניהם, היא שאלת הבעלות, יפנו בסעד מתאים לבית המשפט המחוזי המוסמך לדון בשאלת הבעלות, חלף עמידה על קיומו של ההליך דנן כעת. ניסיון זה לא צלח בידי שכן התובעים עמדו על בירור ההליך בפני ערכאה זו, ולפיכך לא נותר לי אלא לפסוק בתביעה שהובאה בפניי.

ב. טענות הצדדים

עיקרי טענות התובעים

9. התובעים טוענים כי רכשו את הדירה בשלמות, כפי שעולה אף ממרשם המקרקעין, ולפיכך הם גם בעלי אותם שטחים שגרע התובע מהדירה לטובת החנות.
10. לטענת התובעים, אף בהליך ההתמחרות נאמר להם במפורש כי ביכולתם להגיש תביעה לפינוי הנתבע מהשטח בדירה בו תפס חזקה בלעדית.
11. התובעים טוענים כי בעת שהיה הנתבע בעליה של הדירה הוא שיעבד אותה בשלמות לבנק המזרחי כנגד קבלת הלוואה. מכך מבקשים התובעים ללמוד כי גם בהליך המכירה שהתקיים משעה שלא עמד הנתבע בהתחייבויותיו הכספיות כלפי הבנק, התייחסה המכירה לדירה המשועבדת, היא הדירה במלואה.
12. התובעים מציינים כי בהתאם להוראת ראש ההוצאה לפועל, נרשמה הדירה על שמם בשלמות ואף דיווחיהם לרשויות המס בוצעו על בסיס רכישת הדירה במלואה ללא גריעת שטח כלשהו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

13. לטענת התובעים, בחודש דצמבר 2009, לאחר ששילמו במיטב כספם וקיבלו את החזקה בדירה, התברר להם לתדהמתם כי הנתבע גרע שטח נוסף מעבר ל-5 המ"ר אשר הוזכרו עוד בהליך ההתמחרות (הבזיידעם).

עיקרי טענות הנתבע

14. הנתבע טען בכתב הגנתו לחוסר סמכות המפקחת לדון בהליך זה משום שעל אף שהסעד המבוקש הוא הסגת גבול, עיקרו נעוץ במחלוקת הנוגעת לבעלות במקרקעין. נטען כי קביעת הבעלות במקרקעין מסורה לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המחוזי ולכן אינה חוסה תחת סמכויות המפקחת. בהמשך ההליך, הודיע ב"כ הנתבע כי איננו עומד על טענת חוסר הסמכות (ראה פרוטוקול הדיון מיום 5.2.14, עמ' 1 שורה 36).

15. לטענת הנתבע, התובעים מנועים ומושקקים מלטעון כל טענה הנוגעת לבעלות על השטח המסופח, שכן עוד בטרם רכישת הדירה מכונס הנכסים ועל בסיס המידע שבידם בדבר קיומו של השטח המסופח, הצהירו כי ברצונם לרכוש ולקבל את הדירה במצבה הפיסי והתכנוני as is. הנתבע מדגיש כי גם הסכום ששולם על ידם נגזר מגריעת השטח המסופח מהדירה.

16. לטענת הנתבע, הצהרות התובעים המעוגנות בהסכם המכירה בדבר ויתורם על כל טענה כנגד כונס הנכסים הנוגעת למצבו הפיסי התכנוני והזכויות הנלוות לנכס, מהוות למעשה ויתור ומחילה על כל טענה דומה אך ביחס אליו.

17. עוד נטען, כי התובעים מושקקים מלהעלות טענה לבעלות בשטח המסופח מחמת מעשה בית דין או השתק עילה או פלוגתא. לטענת הנתבע, שאלת הבעלות הוכרעה במפורש או במשתמע על ידי רשם ההוצאה לפועל, אשר לטענת הנתבע, אישר את מכירת הדירה אך ורק מן הטעם שהיא איננה כוללת את השטח המסופח.

18. לטענת הנתבע, התובעים השתהו בהגשת תביעתם כאשר שיהוי זה גרם לו נזקים ובמהלכו הוא שינה את מצבו לרעה.

19. עוד טוען הנתבע כי התובעים מושקקים או מנועים להעלות טענת בעלות לגבי השטח המסופח שכן לא דרשו ולא הצהירו כי בכוונתם לתבוע שטח זה. נטען כי לו היו מצהירים כך, לא הייתה משתכללת העסקה מלכתחילה כיוון שאישור רשם ההוצאה לפועל ניתן בשים לב לבקשת כונס הנכסים לאישור העסקה ולתמורה, ולצורך כך נלקחה בחשבון גריעת השטח המסופח.

20. הנתבע טוען עוד כי היה בידי כונס הנכסים להעלות את הטענות המועלות על ידי התובעים, שכן הם באו בנעליו. לפיכך כל טענה שלא הועלתה על ידי כונס הנכסים או הליך שלא ננקט על ידו, מהווה ויתור או מחילה והתובעים אינם יכולים עוד להעלותה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

21. נטען כי היות והתובעים רכשו את זכויות הבנק ומשם נגזרת זכות עמידתם בתביעה זו, הם אינם יכולים לעמוד במצב משפטי מיטיב מול זה שהיה יכול בנק המזרחי לעמוד בו.
22. הנתבע מדגיש כי התובעים לא שילמו כלל עבור השטח המסופח, כי הם מעולם לא העלו טענה כנגד מאן דהוא שהוטעו לחשוב כי הם רוכשים גם את השטח המסופח, וכי רכישתם את הדירה נעשתה בידיעה ברורה שהיא אינה כוללת את השטח המסופח.
23. עוד מדגיש הנתבע כי אף בנק המזרחי התקשר עמו בהסכם למתן אשראי על בסיס שומה אשר לא כללה את השטח המסופח. בהקשר זה נטען כי בשל כך היה הבנק מנוע מלהעלות כל טענה ביחס לשטח המסופח, שכן ויתר מראש וביודעין על נקיטת צעדים משפטיים ביחס לשטח זה.
24. לטענת הנתבע, אישור המכירה בידי רשם ההוצאה לפועל, בכל הנוגע לגובה ההצעה הזוכה, היה בהתחשב בנסיבות לפיהן לא היה בכוונת הנתבע להשיב את השטח המסופח. הנתבע טוען כי ככל שהיה מציע להשיב את השטח המסופח, לא הייתה העסקה יוצאת אל הפועל במחיר הצעת התובעים.
25. הנתבע טוען כי בהיותו בעליה בעבר של הדירה ושל החנות גם יחד, הוא היה זכאי ליצור שינויים פנימיים בדירות אלו, להתחייב לעשות בהן עסקה, ליתן רשות בלתי הדירה לצדדים שלישיים או לשעבדם בזיקת הנאה לצורך מקרקעין אחרים או בני אדם.
26. הנתבע טוען עוד כי בעצם הסיפוח הוא התחייב לעשות בשטח המסופח עסקה או העניק זכות שימוש בלתי הדירה באופן בו יצר הסתמכות אצל המקבל ושינה מצבו לרעה.
27. לטענת הנתבע, בסיפוח השטח ובחלוקת החלקות מחדש, הועברו זכויותיה הקנייניות או החוזיות של הדירה לטובת החנות הלכה למעשה, גם אם לא באמצעות רישום פורמאלי.
28. הנתבע טוען כי הוא זכאי לעשות בשטח המסופח שימוש ללא תמורה. לטענתו, במועד הרלוונטי לסיפוח השטח קיבל את רשותם הבלתי הדירה של בעלי החלקה, ובהסתמך על רשות זו שינה מצבו לרעה. בין היתר, כך נטען, השקיע השקעות מרובות אשר היו כרוכות בשינוי הקירות הפנימיים.
29. לחלופין טוען הנתבע כי סיפוח השטח מהווה הלכה למעשה התחייבות לעשיית עסקה מול הבעלים הרשום אותה עת (הוא עצמו).
30. לחלופי חלופין טוען הנתבע כי הוא מחזיק בשטח המסופח בנסיבות המקימות לו זכויות שבדין מכוח זיקת הנאה בהתאם לסעיפים 92, 93 ו-98 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969. לטענתו, זיקת ההנאה הייתה לטובתו או לטובת באי החנות או לטובת המקרקעין הזכאים ונועדה לאפשר את הגדלת שטח החנות לנוחות בעלי החנות והקונים.
31. לטענת הנתבע, חוסר תום לבם של התובעים שולל מהם אפשרות להעלות כל טענה ביחס לדרישת הכתב, או טענה כי הסתמכו בתום לב על המרשם. לטענתו, התובעים ידעו כל העת כי הרישומים אינם הולמים את מצבה הפיסי התכנוני והמשפטי של הדירה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

32. נוכח האמור לעיל טוען הנתבע כי אין גם לחייבו בתשלום דמי שימוש ראויים.

ג. דיון והכרעה

33. לשם הכרעה בהליך דנן, שעניינו בסעד הנוגע להסגת גבול במקרקעין, יש להקדים ולבחון את שאלת הבעלות בדירה - האם אכן רכשו התובעים את הדירה בשלמותה או שמא רכשוה בלעדי השטח המסופח.

34. אמנם ב"כ התובע הודיע כי איננו עומד עוד על הטענה בדבר חוסר סמכותי לדון בהליך, אולם למען הסדר הטוב אקדים ואדון בשאלת הסמכות, שכן אם אינני מוסמכת לדון בהליך יהא מדובר בפסק דין שהוא בבחינת void.

35. אקדים ואציין כי מצאתי שאכן בסמכותי לדון בשאלת הבעלות כבעניין שבגררא. אנמק.

36. אין חולק כי למפקח על רישום מקרקעין נתונה הסמכות לדון בתביעה בה הסעד המבוקש הוא סילוק יד מדירה בבית משותף, נוכח טענה להסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת. סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") קובע-

סמכות להכריע בסכסוכים

37. 72. (א)

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) ...

(ד) ...

38. הנה כי כן, המפקח מוסמך לדון בסכסוך בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת, וזהו הסכסוך הנדון בהליך זה.

39. אולם, האם מוסמך המפקח לדון בעניין שבגררא בשאלת הבעלות, אשר כשלעצמה מצויה בסמכות בית המשפט המחוזי?

40. בסעיף 74 לחוק, הושוו סמכויותיו של המפקח לסמכויותיו של בית משפט השלום: "למפקח הדן בסכסוך יהיו את כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית".

41. סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 קובע כך:

"סמכות נגררת



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

הובא עניין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו עניין אף אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר".

42. בבר"ע 587/83, **ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 נ' דן ירדני**, פ"ד לח (4) 487, דן בית המשפט העליון, בין היתר, בסוגיית סמכותו של המפקח לדון בעניין שבגררא במסגרת תובענה לסילוק יד שהוגשה לפניו. כך קובע שם כב' השופט ש' לוי:

"האם הוסמך המפקח לדון בעניין שבגררא, בגדר תובענת סילוק היד שהוגשה לפניו, בזכויותיהם ה"קנייניות" של המשיבים? לדידי אין הדבר מוטל בספק; כך הוחלט כבר לעניין הפקיד המוסמך לפי חוק בתים משותפים [נוסח משולב], קודמו של המפקח, שהמחוקק לא הקנה לו, כמו למפקח, סמכויות של בית-משפט שלום: ע"א 191/66[5], והוא - כדי למנוע תוצאה, שעל-פיה "יבצר מהפקיד המוסמך לעשות את המלאכה שהחוק הטיל עליו" (ראה דעת הרוב, מפי השופט זוסמן ז"ל, כתוארו אז, שם, בעמ' 510); קל וחומר הוא במפקח, שהוא "בית-דין" למהדרין: ע"א 44/72[3], שסמכויותיו הן כסמכויות בית-משפט שלום; כפי שמוסמך המפקח ליתן צו הריסה, כמו בית-משפט שלום בגדר סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] (מקודם סעיף 34 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957): ע"א 768/80[6], כך רשאי הינהו, לצורך העניין שלפניו, לדון בגררא בשאלה, שהכרעתה דרושה לבירור העניין, אף אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית המשפט המחוזי (סעיף 76 לנוסח המשולב, מקודם סעיף 35 לחוק משנת תשי"ז); וכבר נפסק, שלא ברשות שביסקול-דעת עסקין אלא בסמכות חובה: ע"א 89/63[7]. והשווה: ע"א 510/82[8]"

43. וראה גם דברי כב' השופטת מ. נאור בע"א 10112/03, גיטה פן נ' דן טרלן- אסן ואח' (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 4.10.09):

"סמכויותיו של המפקח הזהות לסמכויותיו של שופט בית משפט שלום הן בתביעה אזרחית וכן העובדה שערעור על החלטותיו של המפקח מוגש לבית המשפט המחוזי "מצביעות על האופי השיפוטי של התפקיד אותו ממלא המפקח בדונו בסכסוך בין בעלי דירות" (ראו והשוו ע"א 5086/07 פולק נ' בן מאור [פורסם בנבו], 7.2.2008) אשר עניינו סמכות בית משפט זה לדון בפסלות מפקח). משכך רשאי המפקח לדון בגררא בשאלה שהכרעתה נדרשת לבירור העניין שלפניו (ראו עמדת השופטים ש' לוי ו-ד' לוי ב-ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' ירדני, פ"ד לח (4) 487, -496 (1984))" (ההדגשות שלי- י.ע.ש.)

44. הנה כי כן, נקבע כי לצורך בירור המחלוקת רשאי המפקח לדון בגררא בשאלה המצויה בסמכותו הייחודית של בית המשפט המחוזי. לפיכך, מצאתי כי בסמכותי לדון בשאלת הבעלות בדירה על מלוא שטחה הרשום, ובעיקר בשאלת הבעלות בשטח המסופח, כעניין שבגררא.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

45. היות וכך, מובן כי קביעותי לעניין הבעלות אינן מהוות מעשה בי-דין בתביעת בעלות ואף לא פלוגתא פסוקה (ראו ע"א 476/88 שושנה אשת נ' עליזה נפתלי פ"ד מה (2) 749; ראו גם א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה עשירית (תשס"ט), עמ' 49-51).

הבעלות בשטח המסופח

46. מכאן אפנה לבחינת השאלה מיהו בעל זכויות הבעלות בשטח המסופח ובהתאם לצורך- האם הנתבע הוא בעל זכויות כלשהן בשטח המסופח הגוברות על יכולת התובעים לדרוש את סילוק ידו משם.

47. אפתח בעניין נטל ההוכחה. הלכה פסוקה היא כי התובע סילוק ידו של מחזיק ממקרקעין, מכוח בעלות בהם, די שיוכיח כי הוא הבעלים ומכאן ואילך נטל ההוכחה מוטל על הנתבע, להוכיח זכותו להמשיך ולהחזיק במקרקעין:

"בתביעה שכזו די לתובע להוכיח כי הוא הבעלים החוקיים של המקרקעין, ואז עובר נטל הראייה לנתבע להראות שהוא רכש זכות כלשהי במקרקעין, אשר זכות הבעלות כפופה לה" (ע"א 16482/90 עיריית תל אביב יפו נ' גרינשטיין, פ"ד נג 313, 354; ע"א 483/62 קוק נ' לנדוי, פ"ד י"ז 1953).

48. לפיכך, ראשית על התובעים להוכיח את בעלותם במלוא שטחה של הדירה. ככל שיעלה בידם לעשות כן, או אז יעבור נטל ההוכחה אל הנתבע להוכיח כי הוא זכאי להמשיך ולהחזיק בשטח המסופח.

49. לאחר שבחנתי את כלל הראיות ושמעתי את עדי הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, במובן זה שיש להורות על סילוק ידו של הנתבע מהשטח המסופח ומיתר שטחי הדירה אשר בפועל סופחו לחנות או שהנתבע עושה בהם שימוש ייחודי בכל דרך אחרת.

50. אנמק מסקנותי להלן.

51. ראשית יש לפנות אל הסכם המכר (צורך כנספח ח' לתצהירי הנתבע- להלן: "הסכם המכר"), שם מפורט מהו הנכס הנמכר לתובעים באופן הבא:

"מקרקעין המהווים את הדירה הנמצאת ברחוב עמוס 19 ירושלים והידועה ברישומי בלשכת רישום מקרקעין בירושלים כחלקה 61/1 בגוש 30092 (המקרקעין הנ"ל וכל הזכויות בהם ובגינם, להלן: "הנכס").

52. עוד מצוין בהסכם המכר כך:

"והואיל:

והכונס מעמיד את הנכס למכירה במצבו הנוכחי מבחינה פיסיית ותכנונית ומשפטית ובכלל זה מצהיר כי למיטב ידיעתו, בהסתמך על שמאות שנערכה לבקשתו, נגרעו משטח כ-5 מ"ר לטובת חנות שכנה הידועה כחלקה 61/2 ואשר רשומה אף היא בבעלות החייב..



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

והואיל:

והכונס מעמיד את הנכס למכירה במצבו כפי שהוא (as is) ללא כל התחייבות כלפי הקונה לפעול להשבת השטח שנגרע מן הדירה אך ימחה לקונה את הזכות, ככל שהיא קיימת, לתבוע בעצמו מן החייב את השבת השטח לאחר שישלים את התחייבויותיו במלואן כלפי הכונס".

53. כנהוג בהליכי מכירה שמבוצעים באמצעות רשות ההוצאה לפועל, הוציא ראש ההוצאה לפועל צו (ראה צו מיום 11.6.09, צורף כנספח לתצהירי התובעים- (לא סומן)- להלן: "צו המכירה") המורה ללשכת רישום המקרקעין על רישום המכר באופן הבא:

" מכוח סמכותי עפ"י תקנה 69 לתקנות ההוצאה לפועל התש"מ-1979 ועל סמך האמור בסעיף 34א' לחוק המכר תשכ"ח-1968, אני מורה בזאת ללשכת רישום המקרקעין בירושלים ולעיריית ירושלים

להעביר את הזכויות בנכס שלהלן משמו של החייב ולרשום על שם הרוכשים את כל הזכויות בנכס המפורט להלן ובגינן

מקרקעין המהווים בית הנמצא ברחוב עמוס 19 ירושלים והידוע ברישומו בלשכת רישום המקרקעין בירושלים בגוש 30082 חלקה 61/1 ירושלים (להלן: "הנכס") כשהן נקיות מכל שיעבוד, עיקול וזכות אחרת ובכפוף לתשלומי המס החלים על הרוכשים על פי דין בקשר עם רכישת הנכס"
(ההדגשות במקור- י.ע.ש).

54. בהקשר זה יש לציין כי לא נעלם מעיני ראש ההוצאה לפועל כי קיים שטח של כ- 5 מ"ר אשר סופח לחנות משטח הדירה. הדבר עולה מפורשות מהחלטתו מיום 26.4.09 בבקשת כונס הנכסים לאישור הסכם המכר ובהתנגדות הנתבע לכך (ראה נספח יא לתצהירי הנתבע). כך למשל מצוין שם בסעיף 3- " הערכת השמאי לקחה בחשבון גריעה נטענת של כ- 5 מ"ר מתוך הנכס לשטח בפועל של נכס צמוד, המצוי גם הוא, כפי הנראה, בבעלות החייב". אף על פי כן, ציווה רשם ההוצאה לפועל על רישום בעלות התובעים בדירה בשלמות.

55. לפיכך טענת הנתבעים כי שאלת הבעלות הוכרעה כבר על ידי רשם ההוצאה לפועל אשר כביכול אישר את מכירת הדירה אך ורק מן הטעם שהיא איננה כוללת את השטח המסופח, אין בה כל ממש. אין בהחלטות רשם ההוצאה לפועל כל אמירה ממנה ניתן ללמוד כי מכירת הדירה אושרה מן הטעם שאיננה כוללת את השטח המסופח, כנטען.

56. לפיכך, **ובהתאם לאמור בצו המכירה**, נרשמו התובעים כבעלי הדירה בשלמות במרשם המקרקעין.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

57. עולה, אם כן, הן מניסוח הנמכר בהסכם המכר והן מצו המכירה, כי הנכס נמכר בשלמותו לתובעים, וזאת תוך יידוע התובעים כי מצב הנכס בפועל הוא כזה בו נגרעו ממנו 5 מ"ר לטובת החנות. בהסכם המכר אף צוין מפורשות כי ככל שקיימת זכות תביעה להשבת אותו "שטח מסופח", מומחה זכות זו לתובעים.

58. אין ספק כי לתובעים הובהר דבר מצבה הפיסי של דירה 1 - הובהר להם כי נגרע ממנה בפועל שטח של כ-5 מ"ר לטובת החנות, והובהר להם כי ככל שקיימת לכונס הנכסים, הבא בנעלי בנק המזרחי, זכות תביעה להשבת השטח המסופח - זכות זו מועברת אליהם. אף על פי כן, גם בהסכם המכר וגם בצו המכירה הובהר מפורשות כי התובעים קונים את הדירה **בשלמות**, וכך הם אף נרשמו בפועל במרשם המקרקעין - כבעלים בשלמות של הדירה.

59. אין בידי לקבל את טענת הנתבע, לפיה כביכול העובדה שבהסכם המכר צוין כי התובעים רוכשים את הדירה "as is" (ראה ב"הואיל" הרביעי) וכן כי " הכונס מעמיד את הנכס למכירה במצבו הנוכחי מבחינה פיסי, תכנונית ומשפטית..." (ראה ב"הואיל" השלישי) משמעותה כי ויתרו על השטח המסופח. עיון בהסכם המכר מעלה כי סעיף זה נועד לוודא כי התובעים מודעים לכך שהם רוכשים את הדירה במצבה הקיים, קרי תוך שהם מכירים בעובדה כי השטח המסופח צורף בפועל לחנות. אולם, אין בהסכם המכר כל אמירה לפיה הדירה נמכרת ללא השטח המסופח. ההפך הוא הנכון, כאמור, בהסכם המכר הובהר מפורשות כי הנכס הנמכר היא הדירה בשלמותה וכי זכות התביעה להשבת אותו שטח מסופח, ככל שקיימת, הומחתה לתובעים מכונס הנכסים.

60. לא מצאתי גם בסיס לטענה כי הצהרות התובעים המעוגנות בהסכם המכר בדבר ויתורם על כל טענה כנגד הכונס הנוגעת למצבו הפיסי התכנוני והזכויות הנלוות לנכס, מהוות למעשה ויתור ומחילה על כל טענה דומה אף ביחס לנתבע. הנתבע מבקש ללמוד מהסכם המכר את מה שאין בו. משמעות הסעיף הוא כי התובעים מצהירים בו שהם מודעים למצבה של הדירה, ובכלל זה לעצם הכללתו בפועל של השטח המסופח בתחומי החנות, ובהקשר זה מוותרים על טענות כנגד כונס הנכסים (כך למשל לא יוכלו לטעון כלפיו כי מכר להם דירה בה קיימת פלישה או כל טענה דומה). דא עקא, אין כוונתו של סעיף זה בהסכם המכר כי התובעים מוותרים על זכותם, ככל שקיימת, להשיב את השטח המסופח לדירתם. ההפך הוא הנכון, בהסכם המכר נאמר ברחל בתך הקטנה כי – " ... (כונס הנכסים - י.ע.ש) **ימחה לקונה את הזכות, ככל שהיא קיימת, לתבוע בעצמו מן החייב את השבת השטח**".

61. בכך יש משום מענה גם לטענת הנתבע לפיה משלא תבע כונס הנכסים את השבת השטח המסופח מן הנתבע הרי שוויתר על זכותו בהתנהגות, ואין התובעים יכולים לעשות זאת במקומו. לא הוכח בפני כי בנק המזרחי ויתר באופן כלשהו על השבת השטח המסופח לדירה, או על טענתו כי השטח המסופח



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

מהווה, באופן חוקי, חלק משטח הדירה. עובדה היא, כי הדירה מושכנה לבנק בשלמותה, אף לאחר ביצוע הסיפוח בפועל. העובדה כי בשומת השמאי יואל גנני מיום 11.2.02 (נספח ד לתצהיר הנתבע), עליה הסתמך הבנק טרם מתן ההלוואה, לא ניתן ערך כספי לאותו שטח המסופח, אין בה די כדי ללמוד על ויתורו של הבנק לגבי זכותו ביחס למלוא הדירה, זכות עליה מעיד שטר המשכנתא. בנסיבות אלו, משהסכם המכר הקנה לתובעים בצורה מפורשת, את הזכות לתבוע את השבת השטח המסופח לדירה, רשאים התובעים להגיש תביעה זו, כמי שבאו בנעלי הבנק ובנעלי כונס הנכסים.

62. זאת ועוד. לכאורה, לו היו התובעים רוכשים את הדירה ללא אותו שטח מסופח, ניתן היה לרשום את בעלותם בחלקים היחסיים של הדירה אותם הם קונים (אם קנו 34 או 36 מ"ר בלבד, המשמעות היא כי חלקם היחסי בבעלות בדירה 1 הוא כ- 82/100 ונותרה בעלותו של הנתבע בכ- 18/100 חלקים). לחלופין ניתן היה לרשום אותם כבעלי זכות חכירה לדורות בחלק מסוים מהדירה - היינו אותו חלק ללא השטח המסופח. דא עקא, כי לא כך נוסח הסכם המכר או צו המכירה. משני מסמכים מהותיים אלו עולה למעשה כי הנמכר הוא **הדירה בשלמותה**. כאמור, באופן זה אף נרשמו התובעים במרשם המקרקעין-כבעלי הדירה בשלמות.

63. אינני מקבלת את טענת הנתבע כי ניתן ללמוד מהשומות שנערכו לדירה (הן לצורך קבלת הלוואות מהבנקים השונים- קבלת המשכנתא, והן לצרכי המכירה בהליכי ההוצאה לפועל) כי הדירה נמכרה רק בחלקה לתובעים, ללא השטח המסופח. התרשמתי כי דווקא ההפך הוא הנכון.

64. בשומה שערך השמאי יואל גנני (להלן: "**גנני**") ביום 17.9.98 לבנק לאומי (להלן: "**שומת גנני הראשונה**") - ראה נספח ג' לתצהירי הנתבע) מצוין במפורש כי השטח המסופח הוא באופן רשמי חלק בלתי נפרד מהדירה. עם זאת, גנני לא התעלם מעצם קיומו של השטח המסופח ובחר במסגרת הערכת שוויו של הנכס שלא להביא בחשבון שטח זה.

65. הצדדים בחרו שלא לזמן את גנני לעדות ולא להעמיק חקר מעבר ללשון השומה בעקרונות עליהן התבססה.

66. במצב דברים זה, ומקריאת שומת גנני הראשונה, נראה כי גנני בחר שלא לתת לאותו "שטח מסופח", או אם תרצה - "שטח פלישה" משמעות כלכלית כלשהי בבחינת ערך הדירה. ייתכן כי היה זה מן הטעם שהשמאי ביקש לשקלל את עלות פינוי השטח, בכלל זה ניהול הליכים משפטיים העשויים להיות ארוכים למדי, דבר גם לו משמעות כלכלית. יתכן, כי בשל עובדה שמדובר ב-5 מ"ר בלבד, אותה עלות פינוי משתווה לעלות השטח המסופח. אולם, גנני לא נחקר, ואין אלא אלה בגדר השערות בלבד. מכל מקום, העובדה כי השמאי בחר שלא לתת משמעות כלכלית לשטח המסופח, אולם עם זאת ציין מפורשות כי: "**שטח שהופרד מהדירה (כ-5 מ"ר) לא נלקח בחשבון שומתי, למרות שרשמית שטח זה אמנם מהווה חלק מהדירה**", מלמדת על כך גם השמאי ראה את הדירה והשטח המסופח כיחידה אחת.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

67. כך, גם בשומה נוספת שערך גנני ביום 11.2.02 (למעשה מדובר בעדכון שומתו הראשונה), הפעם לבקשת בנק המזרחי (ראה נספח ד' לתצהירי הנתבע- להלן: "**שומת גנני השנייה**") הוא בחר שלא לחשב במסגרת השומה את השטח המסופח, ולמעשה שם את הדירה בהתאם לאותם עקרונות שהותוו בשומת גנני הראשונה (לפחות בכל הנוגע לאי חישוב ערך השטח המסופח במסגרת שומת הדירה).
68. מסקנתי היא כי על אף שהשומה לא כללה באמתחתה את ערכו הכלכלי של השטח המסופח, לא ניתן ללמוד או להסיק ממנה על כי התבצעה שומה לדירה ללא השטח המסופח מהטעם שהבנק לא ראה בה באופן אמיתי חלק מהדירה ולפיכך חלק מהמשכון.
69. בהקשר זה נמנע הנתבע מלהעיד גורם רלוונטי בבנק המזרחי, אשר יכול היה לאשר את טענותיו לפיהן משכון הדירה בשלמות נעשה לאחר שהבנק הבין לכאורה ששטח הדירה הרשום במרשם המקרקעין איננו נכון, ולפיכך משכון הדירה בשלמותה התייחס לכאורה רק לשטח הדירה בפועל, ללא השטח המסופח. אלא, שהנתבע נמנע מלהעיד גורם כאמור מבנק המזרחי. במצב דברים זה הרי שחלה ההלכה לפיה צד שנמנע מלהציג ראיה רלוונטית או מלהעיד עד רלוונטי, חזקה כי עדותו הייתה משמשת לרעתו (ראה: ע"א 548/78, **שרון נ' לוי**, פ"ד לה (1) 736, ע"א 635/89, **אנקונה נ' גוטמן**, תק- על 90 (3) 705 (1990), ע"א 27/91, **קבלו נ' שמעון**, פ"ד מט (1) 450 (1995), יעקב קדמי **על הראיות- הדין בראי הפסיקה** (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד), עמ' 1650).
70. זאת ועוד. על אף שגנני שם את שווי הדירה ללא השטח המסופח, משכן הנתבע את הדירה **בשלמותה** (ראה שטר המשכנתא מס' 1661/99 – צורף כנספח לתצהירי התובעים- להלן: "**שטר המשכנתא**"). לו אכן סבר אז, כפי שטוען היום, כי גבולות הדירה והחנות שונו בפועל, אולם אך לא ניתן לכך ביטוי במרשמים הפומביים, מדוע בחר למשכן את הדירה בשלמותה? לכאורה היה עליו לדאוג לשינוי גבולות הדירה והחנות במרשם המקרקעין, באופן בו יתווספו באופן רשמי לחנות כ-5 מ"ר משטח הדירה, ולתקן את רישום הבית המשותף בהתאם. לאחר מכן, יכול היה לבטח למשכן את הדירה כששטחה קטן יותר מזה הרשום. אולם, הנתבע בחר שלא לעשות כן והדבר אומר דרשני ביחס לטענותיו.
71. ודוק: מחומר הראיות עולה כי סיפוח השטח לטובת החנות נעשה **עוד קודם** לחתימת שטר המשכנתא. בחוות דעת גנני הראשונה, אשר נערכה כאמור ביום 17.9.98, כבר הייתה התייחסות לסיפוח 5 מ"ר משטח הדירה לשטח החנות. אף על פי כן, כאמור, ביום 7.2.99, המועד בו אושר שטר המשכנתא לרישום (ראה נספח לתצהירי התובעים), מושכנה הדירה **בשלמותה** ולא נעשה כל שינוי בצו רישום הבית המשותף ביחס לגבולות הדירה והחנות ולשטחן.
72. הנתבע ביקש ליתן משקל לעובדה כי בדיווח על עסקת מכר הדירה לרשויות המס דיווחו התובעים על דירה בשטח של 34 מ"ר בלבד (ראה "הצהרה על מכירת/ רכישת דירה" - נספח ט' לתצהיר הנתבע).



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

מכאן, מבקש הנתבע ללמוד כי אף התובעים ראו את הדירה שאותה הם רוכשים כדירה ששטחה איננו כולל את השטח המסופח.

73. מעדות התובע 1 ועדות אמו- הגב' פנינה מועלם, התרשמתי כי אכן האמינו בלב שלם, ובהתאם למצג שהציג להם כונס הנכסים, כי הדירה נרכשת על ידם בשלמות, אולם תוך שקיימת בה פלישה מסוימת, והם יכולים לפנות לערכאות המשפטיות על מנת לנסות ולפנות את אותו שטח פלישה (ראה: עדות שמעון מועלם, פרוטוקול מיום 2.7.14, עמ' 2 שורות 40-41, עמ' 3 שורות 6-7, עדות הגב' פנינה מועלם עמ' 5 שורות 31-32).

74. אמנם, התובעים דיווחו על דירתם לרשויות המס כדירה בשטח 34 מ"ר כעולה מהצהרתם על רכישת הדירה, אולם יחד עם זאת רשמו כי הם רוכשים אותה בשלמות (1/1 חלקים). מכל מקום, לא שוכנעתי במכלול הנתונים עליהם עמדתי לעיל, כי מכך יש ללמוד כי התובעים ראו את הדירה שרכשו ככזו שאינה כוללת את השטח המסופח.

75. בשולי הדברים אעיר כי גם כאשר מדובר על עסקה שלא מולאו לגביה חובות הדיווח והתשלום, ניתן למלא את הנדרש, בדיעבד ומשנעשה הדבר – תקפה העסקה מעת עריכתה. ראו, לענין זה, את הוראת סעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין"). על פי סעיף 16(א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין: "**תקפן של מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין החייבות במס מותנה במילוי אחד התנאים האמורים להלן, וכל עוד לא נתמלא, לא תוקנה כל זכות על אף האמור בכל דין; משנתמלא, כוחו למפרע מעת המכירה או מיום הפעולה.**" (ההדגשה אינה במקור).

76. ראו גם את פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 6906/00, **אחמד ענבטאוי (המערער נ' דר (דרויש) רינה, פ"ד נו (5), 280, עמ' 286-287, שם נקבע כי: "...גם אם תוקפה של העסקה מושעה עד לתשלום המס ומילוי יתר תנאי הסעיף, העסקה תקום לתחייה ותתפוס מבראשיתה עם קיום התנאים שבסעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין.**"

77. **מסקנתי היא, אפוא, כי התובעים רכשו את הדירה בשלמותה, כפי שטחה המפורט בפנקס הבתים המשותפים.**

78. משהוכיחו התובעים את בעלותם בדירה, מוטל, כאמור הנטל על הנתבע להוכיח כי רכש זכות כלשהי במקרקעין אשר זכות הבעלות של התובעים כפופה לה.

79. כזכור, הנתבע טוען כי זכויותיו גוברות על זכויות התובעים בין אם מכוח קבלת זכות שימוש בלתי הדירה, בין אם מכוח התחייבות לעשות עסקה, ובין אם מכוח זיקת הנאה.

80. אדון להלן בטענותיו בהקשר זה. כבר עתה אציין כי לא מצאתי בהן ממש.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

רישיון בלתי הדיר במקרקעין

81. על מנת לבחון את טענת הנתבע ל"רשות שימוש בלתי הדירה", יש תחילה לעמוד על מהותה המשפטית של זכות ה"רישיון במקרקעין".

82. פרופ' נ' זלצמן עמדה על הגדרתו של מוסד רשיון זה (במאמרה "רישיון במקרקעין", הפרקליט מב חוברת א (תשנ"ה), 24):

רשיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. "רשות במקרקעין" באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד.... הרשות נעדרת כוונת הקניה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין... ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. רשות גרידא באה להבחין איפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנתנו רשאי לבטלו בכל רגע...."

83. ההסכמה הנדרשת יכולה להיות גם בעל פה ואין חובה כי תינתן בכתב דווקא. בפסק דינו המנחה של בית המשפט העליון, ע"א 815/81, יעקב כליפא ו-2 אח' נ' אלי שאול ואח', פ"ד לו(3), 78, עמ' 84-85, הכיר בית המשפט בתוקפה המחייב של הסכמה בעל פה בין בעלי דירות בבית המשותף, הנוגעת למתן רשות לשימוש ברכוש המשותף, גם אם לא ניתן לה ביטוי רישומי בתקנון ובספר ההחלטות, וכך נקבע שם-

"... מובן מאליו, שהסכמה בעל-פה חייבת להיות מוכחת בראיות מספיקות.
אם היא מוכחת כך, אין כל חשש לאי-ודאות. הרי סעיף 23 של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, מאפשר, בדרך כלל, עשיית חוזה כלשהו בהסכמה בעל-פה. אין לראות טעם, מדוע נכונות זו של המחוקק לתת תוקף להסכמה בעל-פה לא תחול גם על הסכמת בעלי הדירות בבית משותף לטובת אחד מהם..."

ראה לעניין זה גם: ע"א (חיפה) 1020/03, בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף, תק-מח 2004(1), 5244, ע"א 19/81 בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ו-5 אח', פ"ד לז(2), 497, ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטר, פד"י לא 382(1).

84. הרשאה להשתמש במקרקעין אפשר שתהיה לתקופה מסוימת ואפשר שתהיה לתקופה בלתי מסוימת; אפשר שתיווצר בהסכמה פוזיטיבית ואפשר שתיווצר בשתיקה בלבד; אפשר כי היא תהיה הרשאת



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

מתנה או הרשאה כנגד תמורה (ראה: תא (נצ) 73-08 אברהם כץ נ' דינה בן ישי, פורסם ב"נבו" (השופט עילבוני. 5.12.10).

85. בפסיקה קיימת הבחנה בין רישיון שניתן בתמורה לבין רישיון שלא ניתן בתמורה. כך, בע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית-מדרש החסידים**, פ"ד לא(3) 210, נקבע כי כאשר לא ניתנה תמורה מדובר ברישיון שניתן לביטול בכל עת (ראה גם: ע"א 602/84 **ריבוא נ' גל**, פ"ד לט(3) 693 (1985), ע"א 126/83 **אלעלמי נ' אל-חטיב**, פ"ד מ(1) 397 (1986)).
86. יכולתו של מקנה הרישיון לחזור בו ממתן הרישיון בכל עת, כפופה גם להיעדר הסתמכות ושינוי מצב לרעה בהתבסס על מתן רישיון (ראה: ע"א 346/62, **רכטר נ' מנהל מס עזבון**, פ"ד יז (2) 701, ע"א 602/84 לעיל).
87. נפנה, אפוא, לנסיבות במקרה שלפנינו. כזכור, במקרה הנדון טוען הנתבע כי בעל הדירה נתן רישיון בלתי הדיר לבעל החנות לעשות שימוש בשטח המסופח כחלק משטח החנות. נטען, כי בשים לב להשקעות המרובות של בעל החנות בשטח המסופח, לא יכול בעל הדירה לחזור בו ממתן הרישיון באופן בו הפך למעשה הרישיון להיות בלתי הדיר.
88. ספק רב לשיטתי אם אדם יכול ליתן לעצמו רישיון בלתי הדיר באופן הנטען, שכן טענת הנתבע היא כי למעשה בעל הדירה (הנתבע עצמו) נתן רישיון בלתי הדיר לבעל החנות (שגם הוא הנתבע בעצמו).
89. אולם גם מבלי להעמיק חקר בסוגיה זו, הרי בחינת שאר היסודות של מוסד ה"רישיון בלתי הדיר" מובילנו למסקנה כי זה לא התגבש במקרה שלפנינו.
90. ראשית, עסקינן ברישיון שניתן ללא תמורה. הנתבע עצמו לא טען כי קיבל או נתן תמורה עבור אותו רישיון נטען.
91. היות ואין מדובר ברישיון שניתן בתמורה, זכאי למעשה נותן הרישיון לבטלו כ"הרף עין", בכל עת. ככל שאכן ניתן רישיון לשימוש במקרקעין, זכאים התובעים, אשר באו בנעלי הנתבע כבעלי הדירה, לחזור בהם ממתן הרישיון.
92. שנית, הנתבע לא הוכיח כי הוא, כבעל החנות, הסתמך על אותו רישיון ושינה בעקבותיו מצבו לרעה. אמנם, אין חולק כי הנתבע ביצע בפועל שינויים ביחידות, תוך שהוא מספח חלק מהדירה לטובת החנות. דא עקא, הנתבע לא הציג אסמכתאות הנוגעות לכך, ובכלל זה לעלות השינוי (על אף שטען כי השקיע "השקעות מרובות"). לפיכך לא הוכחו יסודות ההסתמכות לאשורם.
93. במצב דברים זה אין לי אלא לדחות את הטענה בדבר קבלת רישיון שימוש בלתי הדיר.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

התחייבות לעשות עסקה

94. לטענת הנתבע, סיפוח השטח מהווה הלכה למעשה התחייבות לעשיית עסקה מול הבעלים הרשום אותה עת (הוא עצמו).
95. התחייבות לעשות עסקה דורשת, ראשית לכל, על פי סעיף 8 לחוק המקרקעין מסמך בכתב- " **התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב**". מדובר בדרישה מהותית וחשובה (ראה: ע"א 9287/07 **חנוך נ' נגר**, מיום 1.3.11, בפסקה 14 לפסק-דינו של כבוד השופט גיבוראן; ע"א 547/09 **חברת אוק אף איי אינבסטמנט קו בע"מ נ' חברת פי בי סי מימון בע"מ**, מיום 23.5.11, בפסקה 5 לפסק-הדין; ע"א 7123/10 **תחנת דלק ראש פינה נ' דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ**, מיום 14.8.12, בפסקה 9 לפסק-הדין).
96. מסמך כזה איננו בנמצא. אמנם, מגמת הפסיקה היא להקל בדרישת הכתב, אולם הפסיקה הכירה בהקלות אלו מקום בו נערך מסמך בכתב, אלא שזה היה חסר בהיבטים שונים. נפסק, כי יש צורך במסמך שיכיל פרטים בסיסיים והוכרה האפשרות להשלים את הפרטים החסרים באמצעות דין או נוהג (ראה: ע"א 235/75 **קאדרי נ' מסדר האחויות צ'רלס הקדוש**, פ"ד ל(1) 800 (1976); ע"א 18/77 **בית חלקה 731, גוש 6668 בע"מ נ' מיכקשווילי**, פ"ד לב(2) 57, 60 (1978), ע"א 7193/08 **עדני נ' דוד**, פסקה 9, (18.7.2010)). בהמשך נפסק כי ניתן להשלים את החסר גם כאשר קיימות ראיות חיצוניות למסמך הכתוב המעידות בבירור על התגבשותה של העסקה וגמירות דעת הצדדים (ראה: "א 664/81 **הווארד נ' ארז**, פ"ד לח(3) 301, 307-308 (1984); ע"א 251/85 **רוטמנש נ' ויניגר**, פ"ד מא(3) 827 (1987); ע"א 5511/06 **אמינוף נ' א.לוי השקעות ובנין בע"מ**, פסקה ט"ו (10.12.2008)).
97. במקרים מתאימים, כך נפסק, ניתן להכיר בהשתכללותה של עסקה במקרקעין גם בהעדר מסמך בכתב כלל, וזאת תוך הישענות על חובת תום-הלב במשא ומתן המוטלת על הצדדים מכוח הוראת סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, וכאשר עולה "זעקת ההגיונות" מתוך נסיבות המקרה (ע"א 986/93 **קלמר נ' גיא**, פ"ד נ(1) 185 (1996)- להלן: "**עניין קלמר**"). לאחר חקיקת החרג בעניין קלמר, שבה הפסיקה וקבעה כי ההידרשות להלכה שנקבעה בעניין קלמר נועדה למקרים חריגים ויוצאי דופן (ע"א 8144/00 **עלריג נכסים (1987) בע"מ נ' ברנדר**, פ"ד נז(1) 158, 168 (2002), רע"א 1681/10 **עיני נ' סידי**, מיום 5.7.10, בפסקה ז להחלטה). לסקירת השתלשלות הפסיקה בכל הנוגע לדרישת הכתב ראה פסק דינה של כב' השופטת חיות- ע"א 8234/09 **שם טוב נ' פרץ**, מיום 21.3.11).
98. במקרה הנדון לא קיים מסמך בכתב כלשהו, ולא מצאתי כי נסיבות המקרה הן כאלו שחובת תום הלב מצדיקה להיזקק לטענה בדבר קיומה של התחייבות לעשיית עסקה במקרקעין גם בהיעדר מסמך בכתב כלל.
99. אף אם הייתי מכירה בקיומה של התחייבות לעשות עסקה בהיעדר מסמך בכתב, לא מצאתי כי ניתן להכיר במקרה הנדון בהתחייבות זו ככזו הגוברת על זכותם של התובעים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

100. למעשה, טענה זו של "התחייבות לעשות עסקה" טומנת בחובה בפועל טענה בדבר "עסקאות נוגדות" אשר נעשו כביכול במקרקעין. בעניין זה דן סעיף 9 לחוק המקרקעין הקובע כי: **"התחייב אדם לעשות עסקה במקרקעין ולפני שנגמרה העסקה ברישום חזר והתחייב כלפי אדם אחר לעסקה נוגדת, זכותו של בעל העסקה הראשונה עדיפה. אולם אם השני פעל בתום לב ובתמורה והעסקה נרשמה בעודו תם לב- זכותו עדיפה"**.
101. במקרה הנדון הסיטואציה העובדתית שונה מעט מזו בה דן סעיף 9, שכן הנתבע הוא זה שהתחייב (כבעל הדירה), לטענתו, כלפי עצמו (כבעל החנות), לבצע עסקה. לפני שהסתיימה העסקה ברישום התחייב כונס הנכסים (אשר בא בנעלי הנתבע כבעל הדירה) לעשות כלפי אדם אחר עסקה נוגדת. עם זאת, הפסיקה כבר הכירה בכך שניתן להחיל את הוראות סעיף 9 לחוק המקרקעין גם כאשר אין זהות בין המוכר הראשון לשני, וזאת כאשר המוכר השני הוא מי שבא בנעליו (השווה: ע"א 1117/06 **חברת אלקודס קורפוריישן נ' יורשי המנוח מוחמד עלי עבד אלרחמן**, פסקה 28 (פורסם בנבו), 14/04/10, ע"א 839/90 **רז חברה לבנין בע"מ נ' אירנשטיין**, פ"ד מה(5) 739, 746-747 (1991), שם הוחל סעיף 9 מקום בו המוכר בעסקה השנייה היה יורשו של המוכר בעסקה הראשונה). מכל מקום, העיקרון שקבוע בחוק יפה גם למקרה דנן.
102. היות וניתן לראות בכונס הנכסים כמי שבא למעשה בנעלי הנתבע ובמקומו, הרי שלכאורה לפי לשון סעיף 9 גוברת זכותו של הנתבע, אלא אם כן התובעים פעלו בתום לב ובתמורה והעסקה נרשמה על שמם בעודם תמי לב.
103. התובעים פעלו בתמורה, שכן שילמו עבור קניית הדירה, ערך המגלם, כאמור, גם את העובדה שכ-5 מ"ר ממנה תפוסים. השאלה שיש לבחון היא סוגיית תום לבם. כאן נכנסת לתמונה גם הוראת סעיף 10 לחוק המקרקעין ("**תקנת השוק**"), אשר קובעת כי: **"מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה ובהסתמך בתום לב על הרישום, יהא כוחה של זכותו יפה אף אם הרישום לא היה נכון"**.
104. יש אם כן, לבחון ראשית מהו אותו "תום לב" הנדרש מהרוכש המאוחר בזמן (לפי סעיף 9) וכן תום הלב הנדרש ממי שהסתמך בתום לב על הרישום אף אם זה לא היה נכון (כקביעת סעיף 10).
105. ע"א 109/87 **חוות מקורה בע"מ נ. עלי יונס חסן ואח'**, פדאור (לא פורסם) 93 (3) 261, בעמ' 12 פירש בית משפט העליון, את דרישת תום הלב בסעיף 10 באופן הבא:

"המשמעות הסובייקטיבית של דרישת תום הלב בסעיף 10 מעוגנת היטב בפסיקה, ר' למשל: ע"א 842/79 נס נ. גולדה, פ"ד לו(1) 204, 213 – 212, שם נאמר על ידי השופט ד' לוין:

באמרנו "תום – לב", לעניין זה, די בכך שאותו צד ג' נהג באותה עסקה ובהתקשרותו החוזית ביושר ואמונה – ללא ערמה או עצימת עיניים מלראות עובדות גלויות לעין, העשויות להעמידו על המשמר. אין דורשים ממנו לחקור ולדרוש בנסתר, שמא כך יחשוף ויגלה עובדות חשובות, המשנות פני הדברים ושאינן על פני השטח. לא נדרשת ממנו "מידת חסידות"... ההיגיון שבכך, שאם נחמיר במידת תום הלב הנדרשת, נימצא פוגעים בחיי המסחר השוטפים, שהם דם התמצית של כלכלה חיה ותוססת. שהרי תמיד יקנן בלב המתקשר



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

החשש, שמא אין למוכר זכות קניין בנכס, שמא לא חקר ודרש מספיק ואז, וליתר זהירות וביטחון, ימנע מלהתקשר."

106. באשר לתום הלב של רוכש, נקבע בע"א 4609/99 בעלי מקצוע נכסים (1997) בע"מ נ' סונדרס, פ"ד נו(6) 832 כי :

"המבחן לתום-הלב הוא סובייקטיבי... כלומר, תום-הלב נבחן על-פי ידיעותיו בפועל של הרוכש, ולא על-פי מה שהיה צריך לדעת לפי המבחן החיצוני של האדם הסביר".

(ראה גם מיגל דויטש קניין, כרך א', תשנ"ז-1997, בעמ' 127).

107. בע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נ"ז(2) 385 (2003), מתייחס בית המשפט העליון לחובה של הרוכש הראשון בזמן. נקבע, כי כחלק מחובת תום הלב החלה על מי שרוכש זכות במקרקעין, עליו לרשום הערת אזהרה על מנת להגן על זכויותיו, על זכויות צד שלישי תם לב ובכדי למנוע "תאונה משפטית". בפסק הדין (מפי כב' הנשיא א' ברק, בעמ' 404) נקבע בהקשר זה כך :

"נראה לי כי עקרונית, תום הלב דורש כי מי שהתחייבו כלפיו לעשות עיסקה במקרקעין יעשה ככל יכולתו לרשום הערת אזהרה על דבר העיסקה שנעשתה בפנקסי המקרקעין ("טאבו"). בכך הוא לא רק מגן על האינטרס העצמי שלו, אלא גם מתחשב באינטרס של בעל עיסקה שנייה, אשר עשוי לרכוש הנכס לאחר עיון בפנקסי המקרקעין ומתוך מחשבה מוטעית כי לא נערכה עיסקה ראשונה (ראו נ' זלצמן, "דיני קניין" [50], בעמ' 592). בהימנעותו מעשיית כל האפשר לרישומה של הערת האזהרה הניח בעל העיסקה הראשונה את התשתית ל"תאונה המשפטית" שבעסקאות הנוגדות. בידו היה למנוע זאת, והוא לא עשה כן. בכך, עקרונית, יש משום מחדל שלא בתום לב. עקרון תום הלב דורש כי בעל העיסקה הראשונה יפעל בהגינות, תוך התחשבות בציפייה הסבירה של בעל העיסקה השנייה. על-כן נגזר, עקרונית, מעקרון תום-הלב כי בעל העיסקה הראשונה יעשה ככל יכולתו לרשום הערת אזהרה ובכך ימנע את כניסתו של בעל העיסקה השנייה להתקשרות עם המוכר."

108. ומן הכלל אל הפרט.

109. במקרה הנדון מסקנתי היא כי התובעים, כ"קונים השניים" פעלו בתום לב ובתמורה וזכותם נרשמה בעודם תמי לב. אפרט את נימוקיי.

110. התובעים ידעו כי לפי מרשם המקרקעין, שטח הדירה גדול לפחות ב-5 מ"ר מהשטח בפועל. יתרה מכך, גם טרם שנחתם הסכם המכר, לעת שלב ההתמחרות בלבד, נאמר להם אמנם כי חלק של כ-5 מ"ר מהדירה "תפוס", אולם הובהר להם חזור והבהר מפי כונס הנכסים כי ביכולתם לתבוע את פינוי השטח המסופח (ראה תמליל שיחת התמחרות- נספח ז' לתצהיר הנתבע, בקשה מיום 11.6.14 לצירוף תמליל התמחרות).



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

111. יתרה מכך. גם בעת עריכת הסכם המכר, הרי שהובהר בהסכם המכר מפורשות כי זכותו של הכונס לתבוע את פינוי השטח המסופח הומחתה להם- "כונס הנכסים- י.ע.ש) **ימחה לקונה את הזכות, ככל שהיא קיימת, לתבוע בעצמו מן החייב את השבת השטח**".
112. במצב דברים זה, הבינו הנתבעים כי הם רוכשים את הדירה כדירה שלמה, כאשר בחלקה קיימת פלישה. הטענה לקיומה של "**עסקה נוגדת**" מוקדמת בזמן שערך בעל הדירה עם בעל החנות (ויש לזכור כי מדובר באותו אדם עצמו) לא הובאה כלל לידיעת התובעים בעת הרלוונטית, ומכל מקום לא הובאו לה כל אסמכתאות.
113. אף המחיר ה"מופחת" אותו שילמו עבור הדירה, היינו מחיר אשר לא כלל את השטח המסופח, גילם בתוכו את עובדת הפלישה ולא היה על התובעים להסיק מכך כי הדירה נמכרת ללא השטח המסופח כלל.
114. בנסיבות אלו, ועל אף שהתובעים היו מודעים לקיומה של פלישה, לא מצאתי שנפל פגם בתום לבם, גם לא במועד רישום זכויותיהם במרשם המקרקעין.
115. לא למותר לציין כי בכל הנוגע לביודעם (צירוף אותו חלק של מעין "ביודעם" לחנות), הוכח כי התובעים כלל לא ידעו על פלישה זו טרם הרכישה (ראה עדות אם התובע 1, פנינה מועלם, פרוטוקול הדיון מיום 2.7.14, עמ' 6 שורה 5). התובע ציין בתצהירו כי רק בחודש דצמבר 2009 התברר להם למעשה היקף הפלישה בפועל. בעדותו הסביר כי כוונתו היא לפלישה לאותו "ביודעם" מעבר לפלישה לשטח המסופח (ראה עמ' 3 שורות 27-31). עדותו זו לא הופרכה. היינו, בעת רישום זכויותיהם אמנם ידעו כי קיימת פלישה גם לביודעם (בעלותם נרשמה, כפי שעולה מנסח המקרקעין, ביום 26.7.10), אולם לא הוכח כי ידעו על קיומה של עסקה כלשהי ביחס אליו, אלא כי מדובר, לכל היותר, בפלישה בלבד. לפיכך, היו הם תמי לב גם במועד רישום זכויותיהם במרשם המקרקעין גם ביחס לפלישה לביודעם.
116. על הנתבע מצדו, ככל שאכן ראה באותו סיפוח חלקים משטח הדירה לחנות משום "התחייבות לעשות עסקה" כפי שנטען על ידו בהליך זה, היה לפעול בתום לב בעצמו ולדאוג לבצע את כל הפעולות הדרושות על מנת להגן הן על עצמו, והן על צד שלישי תם לב, ולמנוע תאונה משפטית. לפיכך, היה עליו לכל הפחות לרשום הערת אזהרה, אם לא לדאוג לשינוי צו רישום הבית משותף אשר ישקף את גבולות הדירה והחנות כהווייתם. אף הנתבע עצמו טען בסיכומיו ביחס לשינויים בגבולות שבין הדירה לחנות כי "שינויים אלה היו ניתנים לרישום במרשם המקרקעין ובפנקס הבתים המשותפים ללא כל מניעה שבדין" (ראה סעיף 57 לסיכומיו). הנתבע לא עשה כן ומשכך אין לו להלין אלא על עצמו.
117. בנסיבות אלו, אני דוחה את טענת הנתבע כי "התחייבות לעשות עסקה" גוברת כביכול על זכויותיהם של התובעים בדירה. בנסיבות אלו, גוברת זכותם של הרוכשים השניים בזמן (התובעים), אשר קנו את הדירה בתמורה ובתום לב בהסתמך על מרשם, והיו תמי לב גם בעת רישום העסקה במרשם המקרקעין.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

זיקת הנאה

118. זיקת הנאה היא "שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם" (ראה סעיף 5 לחוק). סעיף 93 לחוק קובע את התכנים של זיקת ההנאה. לעניינו רלוונטי ס"ק 93(א)1 הקובע כי: "זיקת הנאה יכול שתקבע- כי בעל המקרקעין הזכאים או מי שהזיקה ניתנה לטובתו זכאי לשימוש מסוים במקרקעין הכפופים".
119. הנה כי כן, הדרישות הטמונות בזכות לזיקת הנאה הן שתיים- היעדר חזקה ושימוש מסוים (לעניין היעדר החזקה ראה ע"א 700/88 **אסטרחאן נ' בן חורין**, פ"ד מה (3) 720 (1991) עמ' 732, ע"א 9308/06 **עיריית רמת גן נ' עזבון המנוחה הגב' ורדה ברנשטיין ז"ל** (פורסם בנבו) כב' הש' עמית מיום 22.9.11 בס' 58).
120. הגישה השלטת בפסיקה היא כי זיקת הנאה היא **זכות מוגבלת מיסודה**. כאשר ההנאה רחבה בהיקפה, חורגת הזכות מהתוכן המקובל של זיקות הנאה (ראו הפ (י-ם) 613/99 **סלמאן נ' עבד אלרחמן** (פורסם בנבו), תא 2154/84 **הפטריארך הארמני נ' אפרהמיאן**, (פורסם בנבו) פ"מ תשמ"ו (2) 492, 509).
121. על זיקת ההנאה כותב המלומד מ' בניאן כך :
- "זיקת הנאה זו זכות במקרקעין הבאה להקנות בתמורה או שלא בתמורה זכות קניינית ומתוך רצון להקנות זכות בעלת סממנים קנייניים במקרקעין ומתן שימוש לא כוללני אלא צר ומסוים וללא זכות לחזקה בלעדית"** (מ' בניאן, "דיני מקרקעין - עקרונות והלכות" בעמ' 402).
122. לפיכך, לא ניתן להכיר בזכות לזיקת הנאה ככזו המבססת זכות של חזקה במקרקעין, ואף לא של שימוש רחב ובלתי מוגבל.
123. בענייננו, מדובר בהחזקה בלעדית של הנתבע בשטח המסופח, אשר אין בינה לבין זיקת הנאה ולא כלום.
124. יתרה מכך. הנתבע לא מבסס את טענתו לקיומה של זיקת הנאה על הסכם המעניק לו זכות שכזו. לפיכך, זיקת הנאה אפשרית במקרה שמתקיימים יסודות סעיף 94 (א) לחוק. סעיף זה קובע כי: "**מי שהשתמש בזכות הראויה להיות זיקת הנאה במשך תקופה של שלושים שנים רצופות רכש את הזיקה והוא זכאי לדרוש רישומה"**.
125. אלא, שהנתבע כלל לא הוכיח כי השתמש בזכות במשך תקופה של שלושים שנים ברציפות, ולמעשה אף טען כי נעשה שימוש במשך כשני עשורים לכל היותר (ראה סעיף 9 לסיכומיו. בשולי הדברים יוער כי אף הטענה לשימוש בשטח המסופח במשך שני עשורים לא הוכחה כלל).
126. מטעמים אלו, אני דוחה את טענת הנתבע להתגבשותה של זיקת הנאה הגוברת על זכותם של התובעים בשטח המסופח.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

שיהוי

127. הנתבע טוען, כאמור, כי התביעה הוגשה בשיהוי שכן הוגשה כחמש שנים לאחר ביצוע רכישת הדירה בפועל.
128. לא מצאתי כי יש בפרק זמן זה משום שינוי המצדיק את דחייתה של התביעה על הסף.
129. כפי שהעידו התובעים הם בחנו במהלך פרק זמן זה את צעדיהם, בין היתר תוך התייעצות עם עורכי דין ומשלוח מכתבים לנתבע בעניין זה (ראה פרוטוקול הדיון מיום 27.14, עמ' 4 שורות 10-12). פרק זמן זה הוא פרק זמן סביר להגשת תביעה מסוג זה בכלל, ובנסיבות בהן הנתבעים לא שקטו על שמריהם - בפרט.

הסגת גבול

130. מסקנתי עד כאן היא, אם כן, כי התובעים רכוש את הדירה בשלמותה, וכי לא קיימות לנתבע זכויות הגוברות על זכות הבעלות של התובעים בדירה.
131. אמנם, בעליו של נכס אינו נהנה מאוטונומיה מוחלטת בבואו להגן על נכסו ואין זכותו הקניינית משמעה "שרירות בעלים" (ראה: יהושע ויסמן, דני קניין- בעלות ושיתוף, עמ' 26-27, 42-45). זכותו להגן על נכסיו מפני פלישה כפופה לעקרונות של תום הלב, ומכוח עקרון זה אף יוגבלו הסעדים להם הוא זכאי (ראה: ע"א 782/70, רדומילסקי נ' פרידמן, פ"ד כב (2) 523, 530, רע"א 6339/97, רוקר נ' סלומון, פ"ד נה (1) 199).
132. הנתבע הפנה לפסק דינה של כב' השופטת חיות בע"א 8661/10 יוסף נעמה נ' תמר טורקיה, (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 21.2.12 – להלן: "פרשת נעמה"), אולם אין הנדון דומה לראייה. במקרה הנדון בפרשת נעמה הוחלט כי על אף קיומה של פלישה מוכחת של דירת המשיבה לדירת המערער בשטח של 2.3 מ"ר, אין להורות על סילוק ידה משם. בית המשפט העליון נתן משקל רב לחובת תום הלב החלה על המערער ועל עקרון ההגינות וקבע כי באותן נסיבות חריגות יש לדחות את תביעת המערער לסילוק יד והריסה. בין היתר, באותו מקרה נמצא כי מדובר בפלישה שבוצעה כעשרים ושש שנים לפני שהמערער הגיש את תביעתו וזאת על אף שהמערער התגורר בדירתו עוד במועד הפלישה. בין היתר נמצא עוד כי במועד בו נכנסה המשיבה להתגורר בביתה היא לא ידעה ולא יכולה הייתה לדעת על דבר קיום הפלישה ועשתה שימוש בלתי מופרע בנכס במתכונתו במשך שני עשורים רצופים לפחות. בנסיבות אלו נמצא כי עקרון ההגינות וחובת תום הלב מטים את הכף שלא להורות על סילוק יד והריסת שטח הפלישה.
133. במקרה הנדון בהליך זה, לעומת זאת, התביעה הוגשה שנים ספורות לאחר שהתובעים רכשו את הדירה ולאחר שמוקדם יותר ניסו לקבל את הסעד שלא על דרך פנייה לערכאות משפטיות. כך גם, הנתבע היה מודע לביצוע הפלישה ועל אף שאין עוררין שיכול היה לעשות כן, הוא עצמו נהג ברשלנות משלא דאג לביצוע תיקון בצו הבית המשותף באופן בו יוסדרו גבולותיהם של החנות והדירה, כל עוד היה הוא בעלי שתי היחידות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

134. במקרה הנדון, וכמפורט לעיל, לא מצאתי כי נפל פגם בתום לבם של התובעים, או כי עקרון ההגינות נוטה במובהק לטובת הנתבע, ולפיכך זכותם להגן על קניינם גוברת על כל זכות נטענת אחרת של הנתבע.

135. במצב דברים זה זכאים התובעים לסעד של סילוק יד.

136. אעיר כי לא דנתי בפסק דין זה בסעדים אשר התבקשו בכתב ההגנה, שעה שלא הוגש כתב תביעה שכנגד.

דמי שימוש ראויים

137. התובעים עתרו בתביעתם לחייב את הנתבע בדמי שימוש ראויים עבור השטח המסופח בסך של 28,750 ₪. סכום זה נטען בעלמא, ומבלי שהתובעים הביאו כל ראיה או חישוב ביחס אליו.

138. בנסיבות אלו התביעה הכספית לא הוכחה, ואין לי אלא לדחותה.

ד. סוף דבר

139. התביעה מתקבלת חלקית.

140. אני מורה לנתבע לפנות ולסלק את ידו מ"השטח המסופח", וכן מכל פלישה נוספת מטעמו לדירה, וזאת בתוך 60 יום מהיום.

141. הנתבע יישא בהוצאות התובעים ובשכר טרחת עורך דינם בסכום כולל של 5,000 ₪.

ניתן היום, טו' טבת תשע"ה, 6 ינואר 2014, בהיעדר הצדדים.

המזכירות תשלח לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת על רישום מקרקעין